

MUHAMMAD HAIRUL NIZAM BIN ABD HAMID

lwn

KETUA PENDAKWA SYARIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato Mohammad Adib bin Hussain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Panel) dan YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) pada 29 Ogos 2022 bersamaan 1 Safar 1444H]

Rayuan Jenayah No. 10000-153-0003-2019

[Percubaan Melakukan Persetubuhan Bertentangan Dengan Hukum Tabii (Seksyen 52(1)(a) dan 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Mohd Shafiq bin Norizan (Tetuan Syafiq Norizan & Associates)*

Responden : *Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 7/11/2019 di dalam Kes Jenayah No.: 10100-153-0018-2019. Di dalam kes tersebut, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (YA Hakim Bicara) telah membuat perintah/hukuman ke atas Perayu seperti berikut:-

- i. *Penjara selama enam (6) bulan;*
- ii. *Denda RM4800.00 atau penjara selama tiga (3) bulan sebagai ganti kepada denda sekiranya gagal bayar denda.*

iii. Sebatan sebanyak enam (6) kali yang hendaklah dilaksanakan di dalam penjara.

[2] Perayu yang terkilan dengan sebahagian hukuman tersebut pada mulanya telah memfailkan Notis Rayuan pada 7/11/2019 yang merayu terhadap hukuman penjara sahaja. Walau bagaimanapun pada 15/11/2019 Perayu telah mendapat perintah penggantungan pelaksanaan hukuman tersebut. Oleh sebab itu, Perayu hanya sempat menjalani hukuman penjara selama sembilan hari sahaja yang dikira dari 7/11/19 hingga 15/11/2019.

[3] Manakala bagi hukuman sebat pula, ia telah selesai dijalankan pada 15/11/2019. Namun begitu, pada 2/2/2021 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan Terpinda yang merayu terhadap hukuman sebatan dan penjara yang telah dan belum dilaksanakan.

[4] Perayu selanjutnya telah mengemukakan Petisyen Rayuan pada 6/10/2021. Manakala Rekod Rayuan pula telah difailkan pada 18/10/2021 dan disempurnakan kepada Responden pada 20/10/2021.

[5] Bagi penghujahan pula, Perayu telah memfailkan hujahannya pada 10/12/2021 diikuti dengan hujahan balas Responden pada 26/1/2021 dan hujahan balas Perayu pada 18/2/2022 sebelum pendengaran di hadapan kami ditetapkan pada 8/4/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Merujuk kepada Petisyen Rayuan, Perayu memplidkan satu sahaja alasan rayuannya sebagaimana yang terdapat pada halaman 308-309 Rekod Rayuan iaitu hukuman penjara enam (6) bulan dan sebatan enam (6) kali pada 7/11/2019 tidak

lagi boleh dikuatkuasakan apabila seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995 tidak lagi mempunyai punca kuasa setelah diisytiharkan sebagai tidak berpelembagaan dan tidak sah oleh Mahkamah Persekutuan pada 25/2/2021.

[7] Berdasarkan alasan tersebut dan setelah kami meneliti keseluruhan rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami dapati isu utama yang perlu diputuskan dalam rayuan ini adalah seperti berikut:

- i. Adakah keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes *Iki Putra Bin Mubarak v. Kerajaan Negeri Selangor* pada 25/2/2021 memberi kesan kepada rayuan ini.
- ii. Apakah status keabsahan hukuman pemenjaraan dan sebatan yang telah dijatuhi oleh YA Hakim Bicara terhadap Perayu pada 7/11/2019.

[8] Kedua-dua persoalan ini timbul apabila Mahkamah Persekutuan dalam kes *Iki Putra Bin Mubarak v. Kerajaan Negeri Selangor* (Kes Iki Putra) pada 25/2/2021 telah memutuskan bahawa seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Selangor) 1995 adalah tidak sah dan tidak berpelembagaan. Keputusan tersebut dicapai ekoran daripada cabaran yang dikemukakan oleh Iki Putra Bin Mubarak iaitu salah seorang tertuduh yang dituduh bersama-sama Perayu terhadap keabsahan peruntukan tersebut dari sudut perlembagaan.

[9] Mahkamah Persekutuan dalam kes tersebut antara lain menyatakan bahawa meskipun tafsiran terhadap frasa “*kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam*” (*offences against the precepts of Islam*) yang berada di bawah bidang

kuasa Mahkamah Syariah merangkumi aspek yang luas, namun ia masih tertakluk kepada had-had tertentu dalam perlembagaan.

[10] Kesalahan liwat yang menjadi subjek utama dalam kes tersebut termasuk dalam undang-undang jenayah (*criminal law*) dan ia terletak di bawah bidang kuasa persekutuan. Oleh yang demikian, kes tersebut perlu diadili di Mahkamah Sivil dan dalam masa yang sama, undang-undang yang terkandung dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri dianggap tidak sah.

[11] Bagi menjawab kedua-dua persoalan di para [6] di atas, sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak berkaitan dengan prinsip umum dalam perundangan jenayah Islam iaitu seseorang itu tidak boleh dihukum jika tiada sebarang sandaran yang menetapkan hukuman bagi kesalahan tersebut ketika dilakukan. Hal ini berdasarkan dalil surah Al-Isra : 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Sesiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan mengazab sesiapaupun sebelum Kami mengutus seorang rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)”

[12] Nas ini bertepatan dengan kaedah fiqh :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

“Dalam memutuskan sesuatu pada masa itu, hukumlah dengan apa yang wujud pada waktu itu. Dan bukan menghukum dengan hukuman-hukuman yang sebaliknya”.

[13] Selain itu dalam membahaskan perkara berkaitan, Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tashri' Al-Jina'I Al-Islami* menyatakan bahawa kaedah asas dalam perundangan Islam ialah:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Tiada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum wujudnya nas.

Berdasarkan autoriti-autoriti di atas, dapatlah disimpulkan bahawa seseorang itu tidak boleh dihukum selagi tiada peruntukan atau nas yang menetapkan sedemikian.

[14] Berbalik kepada rayuan ini, fakta menunjukkan bahawa kedua-dua hukuman penjara dan sebatan terhadap Perayu telah dijatuhi sebelum kes Iki Putra diputuskan. Dari sudut pelaksanaannya, hukuman penjara terhadap Perayu belum dapat dijalankan sepenuhnya setelah Mahkamah Bicara membenarkan penggantungan pelaksanaan hukuman pada 15/11/2019. Hal ini berbeza dengan hukuman sebat yang telah disempurnakan pada hari yang sama.

[15] Berdasarkan situasi dan autoriti yang telah dinyatakan, kami berpandangan bahawa keputusan kes Iki Putra tidaklah mempunyai kesan kebelakang (*retrospective effect*) terhadap hukuman penjara dan sebat yang telah dijatuhi oleh YA Hakim Bicara. Oleh yang demikian, hukuman serta pelaksanaan bagi kedua-dua hukuman tersebut adalah sah setakat undang-undang yang terpakai pada waktu itu.

[16] Apabila kami membuat dapatan sedemikian, maka ia memberi maksud tempoh pemenjaraan yang masih berbaki tidak lagi boleh dikuatkuasa dan dilaksanakan. Hal ini kerana seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1993 dianggap telah tidak wujud setelah diisytiharkan tidak

berpelembagaan dan tidak sah sejak 25/2/2021 sekali gus menyebabkan hilangnya punca kuasa hukuman bagi kesalahan ini.

[17] Dengan hormatnya kami menyatakan bahawa pendirian ini secara asasnya adalah selari dengan kes *Nurfaiz bin Abu Seman lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* [Rayuan Jenayah No: 10000-153-0004-2019] yang telah diputuskan pada 25/6/2021. Panduan yang diberikan dalam kes tersebut kemudiannya telah diikuti dalam kes *Khairul Nizam bin Mohamed lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* [Rayuan Jenayah No: 10000-153-0007-2019], *Mohamad Safwan bin Pishal lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* [Rayuan Jenayah No: 10000-153-0006-2019] dan *Mohd Saharemey bin Azemin lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* [Rayuan Jenayah No: 10000-153-0005-2019] yang masing-masing diputuskan pada 21/6/2022 – *Kes-kes Belum Dilaporkan*.

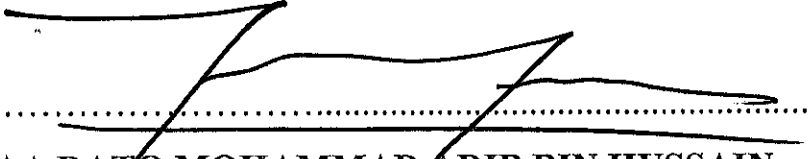
[18] Secara kesimpulannya kami menyatakan sungguhpun hukuman yang dijatuhi oleh YA Hakim Bicara terhadap Perayu adalah sah, namun dari sudut pelaksanaannya menjadi terhenti sebaik sahaja peruntukan seksyen 28 tersebut kehilangan punca kuasa apabila diisytiharkan tidak sah dan tidak berpelembagaan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Petisyen Rayuan, Rekod Rayuan serta hujah kedua-dua belah pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

Bahawa baki tempoh hukuman penjara selama enam (6) bulan yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap Perayu dalam Kes Jenayah No: 10100-153-0018-2019 pada 7/11/2019 adalah **TIDAK DIKUATKUASAKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO MOHAMMAD ADIB BIN HUSSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....
2. YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor